

< 연습문제2>

甲은 乙을 상대로 금 1억 원의 지급을 구하는 매매대금 반환청구의 소를 제기하였다. 그 이후 진행된 1회 변론기일에 출석한 甲이 乙과의 매매계약체결 사실을 주장하자 乙은 “甲이 주장하는 매매계약의 성립 시에 나는 외국에 출장 중이었다”고 주장하였고 이에 대해 甲은 甲 자신과 乙의 이름이 기재되어 있고 甲 자신의 인장과 乙의 인장이 각 날인되어 있는 매매계약서를 증거방법으로 제출하였다. (아래 각 설문은 상호 독립적이고 무관한 것임).

문1. 甲은 2회 변론 기일에 출석하여 “甲이 주장하는 매매계약의 성립 시에 외국에 출장 중이었다”는 乙의 위 주장에 대하여 “이를 그대로 다 인정한다”고 진술하였다. 甲은 그 후 열린 3회 변론기일에 자신의 위 진술을 임의로 철회할 수 있는가? 아니면 법원은 이러한 갑의 이러한 진술을 반드시 판결의 기초로 삼아야 하는가?(15점)

문2. 법원은 2회 변론기일에 위 매매계약서에 대해 증거결정을 한 후 증거조사를 진행 하였다. 乙은 위 매매계약서에 대한 성립의 인부를 함에 있어 위 매매계약서에 찍혀 현출되어 있는 인영은 자신의 인장에 의한 것이지만(인영부분은 인정하지만), 자신은 스스로 날인행위를 한 적이 없다고 부인하였다. 乙의 의사에 기한 날인행위가 있었는지의 여부에 관하여 진위불명에 빠진 경우, 법원은 위 차용증서의 진정성립을 인정할 수 있는가?(15점)

문3. 만약 甲이 제출한 위 차용증서의 진정성립이 인정된다면, 법원은 甲과 乙 사이에 위 매매계약서의 기재 내용과 같은 매매계약체결 사실을 그대로 인정하여야 하는가? (15점)

문4. 만약 乙이 위 매매계약서에 대한 날인사실을 인정한 후, 위 매매계약서가 백지 상태로 작성 · 교부되었고, 甲이 추후 위 매매계약서에 그 내용을 기재한 것(즉 백지 부분을 보충한 것)이라는 사실을 증명하였다면, 법원은 그 상태에서 위 매매계약서의 진정성립을 인정할 수 있는가?(15점)

문5. 만약 乙이 위 매매계약서에 대한 성립의 인부절차에서 진정성립을 인정하였다가 그 후 소송절차가 불리하게 진행되자 위 매매계약서가 위조된 것이라고 하면서 이를 부인하는 항변을 제출하였다면 법원은 이에 대하여 어떻게 판단해야 하는가? (10점)

<채점 기준>

1. (15점)

가. 결론

갑은 자신의 진술을 임의로 철회할 수 있다(또는 법원은 이러한 갑의 진술을 반드시 판결의 기초로 삼아야 하는 것은 아니고 그와 다른 사실을 인정할 수 있다) (3점).

나. 논거

자백의 의의, 변론주의의 내용 중 하나로서 자백에는 법원 및 당사자에 대한 구속력이 발생, 그 대상이 되는 사실은 원칙적으로 주요사실에 한 한다는 것이 통설, 판례의 입장. 그렇지 않을 경우 자유심증주의에 반하게 됨. 사안의 경우 사안의 경우 을이 계약 성립시에 외국에 출장 중이었다는 주장 내지 진술(현장에 부재하였다는 진술)은 갑이 주장, 증명책임을 부담하는 계약체결 사실과는 양립되지 않는 별개의 사실을 부가하면서 갑의 주장사실을 부정하는 것이기 때문에 이유부 부인에 해당함. 즉 이는 주요사실이 아니라 갑이 주장하는 계약체결사실의 부존재를 추인케 하는 간접사실에 불과하므로 이를 자백하였다 하더라도 자백으로서의 효력(구속력)은 발생하지 않는다 (12점).

2. (15점)

가. 결론

진정성립을 인정할 수 있다(3점).

나. 논거

차용증서는 사문서이다. 사문서의 경우 거증자가 그 진정성립을 증명하여야 한다(제 357조). 그런데 제358조는 사문서에 본인이나 대리인의 의사에 기한 서명이나 날인 또는 무인이 있으면 진정성립이 추정됨을 규정하고 있다.

사안에서와 같이 인영부분은 인정되 날인사실을 부인한 경우, 통설과 판례는 이른바 2단의 추정이론으로 사문서 전체의 진정성립을 추정하고 있다(작성명의의인의 인영부분이 인정되면 그의 의사에 기해 날인행위가 행하여 졌음이 추정되므로¹⁾ 결국 제 358조에 의하여 문서전체의 진정성립이 추정된다). 따라서 을이 인장의 도용사실 또는 모용사실에 대하여(즉 제3자에 의해 날인행위가 행하여 졌음에 대하여) 증명을 하

1) 다만, 날인행위가 을의 의사에 기한 것이라는 추정은 사실상 추정이므로 만약 날인행위가 문서작성 명의인인 을이 아닌 타인에 의하여 행해 진 것이 밝혀지거나 을의 의사에 반하여(강박에 의하여) 또는 을의 의사에 기하지 않고(도용되어) 행해 진 것이 밝혀진 경우에는 그 추정이 깨어진다(대판 93다4151, 94다41324). 이와 같이 날인행위가 작성명의인 이외의 자에 의하여 이루어 진 것이 밝혀져 사실상 추정이 깨진 경우, 문서제출자는 그 날인행위가 작성명의인으로부터 위임받은 정당한 권원에 의한 것이라는 사실까지 증명할 책임이 있다(대판 94다41324).

지 못해 진위불명 상태에 빠진 이상 차용증서의 진정성립은 추정되므로 진정성립을 인정할 수 있다(12점).

문3. (15점)

가. 결론

특별한 사정이 없는 이상 소비대차계약체결 사실을 인정하여 한다(3점).

나. 논거

처분문서란? 실질적 증명력이란?

처분문서의 경우 보고문서와는 달리 형식적 증거력이 인정되면 즉 진정성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 이상 실질적 증거력이 인정된다. 차용증서는 증명하고자 하는 소비대차계약이라는 법률행위의 존재를 나타내는 처분문서이므로 그 진정성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 이상(그 기재내용을 부정해야 할 정도로 분명하고도 확실한 반증이 없는 이상) 그에 기재되어 있는 문언대로 소비대차계약이 체결된 사실을 인정하여야 한다 (12점).

문4. (15점)

가. 결론

갑이 을로부터 백지부분(미완성부분)의 보충 내지 그에 관한 작성권한을 위임받았다는 사실을 증명하지 못하는 한 진정성립을 인정해서는 안 된다(3점).

나. 논거

이른바 2단의 추정이론은 사문서의 내용이 먼저 기재되어 완성된 상태에서 서명이나 날인이 행해진 경우에만 적용되는 것이고, 사안에서와 같이 문서가 미완성 상태에서 서명이나 날인이 행해진 경우에는 적용되지 않는다. 따라서 위 차용증서가 백지상태로 작성·교부되었고, 甲이 추후 위 차용증서에 그 내용을 기재한 것(백지부분을 보충한 것)이라는 사실이 증명된 이상, 거증자인 갑은 을로부터 백지부분의 보충 등 그 작성에 관한 권한을 위임받았음을 증명하여야 하고(증명책임), 이를 증명하지 못하면 위 차용증서의 진정성립은 인정될 수 없다(12점).

문5. (10점)

가. 결론

특별한 사정이 없는 한 위조항변을 배척하여야 한다(3점).

나. 논거

문서의 진정성립에 관한 자백은 보조사실에 관한 것이지만 이에 대하여 재판상 자백

과 같은 구속력이 인정된다(판례). 따라서 법원은 이를 기초로 판단하여야 하고(차용 증서의 진정성립을 인정하여야 하고) 당사자는 이에 관한 자백을 취소하거나 철회할 수 없다. 당사자가 이를 취소 내지 철회하기 위해서는 상대방의 동의가 있거나, 진실에 반하고 착오로 인해 자백하였음을 증명하거나 그 자백이 형사상 처벌받을 제3자의 행위로 인하여 행하여 졌다는 점을 증명하여야만 한다(7점).